

1500418-78.2021.8.26.0404

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Comarca: Orlândia

Foro: Foro de Orlândia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... pelo delito de associação para o tráfico (fls. 437/451). Pugnou, lado outro, pela condenação de ambos os réus pelo delito de tráfico e do réu Ariel pelo delito de posse de arma de fogo de uso permitido. A Defesa, em alegações finais, alegou, preliminarmente, nulidade das provas, as quais teriam sido obtidas por meio ilícito. No mérito, requereu, em relação à ré Tainá, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Orlândia

Foro de Orlândia

2ª Vara

Praça Coronel Orlando, s/nº, Orlandia-SP - cep 14620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500418-78.2021.8.26.0404 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500418-78.2021.8.26.0404

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2209754/2021 - DEL.POL.ORLANDIA, 19412514 - DEL.POL.ORLANDIA, 564/21/415 - DEL.POL.ORLANDIA, 2209754 - DEL.POL.ORLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ARIEL FERREIRA DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia em face de ARIEL FERREIRA DOS SANTOS, com qualificação completa nos autos, pela prática dos crimes previstos no art. 33, "caput", art. 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, na forma do art. 69, "caput", do Código Penal, e no art. 12 da Lei nº 10.823/06; e TAINÁ CLEMENTE CAMARGO, com qualificação completa nos autos, pela prática dos crimes previstos no art. 33, "caput" e art. 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso

material, na forma do art. 69, "caput", do Código Penal.

Consta da peça acusatória que, desde data incerta, mas anterior ao dia 4 de agosto de 2021, até esta data, nos endereços da Avenida E, nº 567, Jardim Boa Vista e Avenida N, nº 1.420, Max Define, nesta cidade e comarca de Orlândia, os réus se associaram para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Notícia também que, no dia 4 de agosto de 2021, por volta das 7h, nos endereços da Avenida E, nº 567, Jardim Boa Vista e Avenida N, nº 1.420, Max Define, nesta cidade e comarca de Orlândia, agindo previamente ajustados e com unidade de propósitos, cada qual aderindo voluntariamente à conduta do outro, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, (a) 3 (três) "tijolos" vedados por plástico aderente e um saco plástico contendo diversos fragmentos da substância maconha, com peso líquido de 1.606,71 gramas; (b) 1 (um) segmento plástico de cor opaca, contendo porção de cocaína, com peso líquido de 2,28 gramas; (c) 116 (cento e dezesseis) segmentos de papel alumínio, contendo porções de crack, com peso líquido de 12,13 gramas; (d) 1 (um) segmento plástico transparente, do tipo zip, contendo porções de crack, com peso líquido de 1,09 gramas; (e) 1 (um) segmento plástico transparente, do tipo zip, contendo 2 (duas) porções de maconha, com peso líquido de 14,02 gramas; (f) 6 (seis) tubos plásticos, do tipo eppendorf, contendo cocaína, com peso líquido de 1,41 gramas; (g) 6 (seis) segmentos de papel alumínio contendo porções de crack, com peso líquido de 1,15 gramas; (h) 24 (vinte e quatro) cartelas de "LSD" (dietilamida do ácido lisérgico) e 2 (dois) comprimidos de ecstasy (MDMA); substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, de uso proscrito no país, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que, no dia 4 de agosto de 2021, por volta das 7h, no interior da residência situada na Avenida E, nº 567, Jardim Boa Vista, nesta cidade e comarca de Orlândia, o réu Ariel Ferreira dos Santos tinha a posse de 6 (seis) munições calibre nominal .38, da marca CBC e outras 2 (duas) munições calibre nominal .32, da marca CBC, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência.

A denúncia foi recebida em 01 de outubro de 2021 (fls. 246/248). Os réus apresentaram resposta escrita à acusação, sem preliminares (fls. 235/240). Não vislumbradas quaisquer hipóteses estabelecidas pelo art. 397 do Código de Processo Penal, designou-se audiência instrutória na qual foram inquiridas as testemunhas arroladas e, ao final, realizou-se o interrogatório dos réus (mídia às fls. 423 - termo de fls. 424/433).

O Ministério Público, em memoriais finais, pleiteou a parcial procedência da ação, absolvendo-se os acusados pelo delito de associação para o tráfico (fls. 437/451). Pugnou, lado outro, pela condenação de ambos os réus pelo delito de tráfico e do réu Ariel pelo delito de posse de arma de fogo de uso permitido. A Defesa, em alegações finais, alegou, preliminarmente, nulidade das provas, as quais teriam sido obtidas por meio ilícito. No mérito, requereu, em relação à ré Tainá, a desclassificação do delito previsto no art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, em caso de condenação, a aplicação da modalidade privilegiada. Quanto ao delito de associação para o tráfico, requereu a absolvição dos acusados ante a ausência de provas. Por fim, em relação ao réu Ariel, que seja condenado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena no mínimo legal e compensando a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, que o réu seja absolvido em razão do princípio da insignificância (fls. 462/487).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública destinada a apurar a responsabilidade de ARIEL FERREIRA DOS SANTOS, acusado da prática dos crimes previstos no art. 33, "caput", art. 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, na forma do art. 69, "caput", do Código Penal e, no art. 12 da Lei nº 10.823/06; e TAINÁ CLEMENTE CAMARGO, acusada da prática dos crimes previstos no art. 33, "caput" e art. 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, na forma do art. 69,

“caput”, do Código Penal.

Consigno desde já que, pautando-se pelas provas produzidas, há que se reconhecer a legalidade do ingresso e a licitude das provas obtidas na busca realizada na residência da ré Tainá. Isso porque, pelos elementos colhidos, existiam fundadas razões para o ingresso, em especial pelo fato de que havia fortes indícios de que parte da droga estaria na casa da ré. Soma-se à isso o fato de que a própria moradora do imóvel e avó da ré, Sra. Marilda, quando ouvida na primeira fase da persecução, afirmou ter permitido a diligência policial. Ainda que em juízo tenha alterado parte do depoimento dado, negando a autorização concedida, tal versão foi totalmente infirmada pelo delegado Dr. Paulo Françolin, arrolado pela própria defesa e ouvido em juízo.

Posto isto, afastada a preliminar, e após atenta análise das peças processuais ofertadas por defesa e acusação, bem como dos demais elementos probatórios produzidos ao longo do iter processual, vislumbra-se claramente a parcial procedência da ação penal.

A materialidade dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido imputados ao réu Ariel restaram satisfatoriamente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 18/28), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 29/30), pelo laudo de constatação (fls. 43/47), complementado pelo laudo definitivo (fls. 193/198), bem como pelo laudo pericial de fls. 182/191, atestando a eficácia das munições para disparos, e ainda pela farta prova oral coligida. A autoria criminosa de Ariel e a configuração dos elementos típicos também são incontestáveis, conforme se demonstrará.

Lado outro, em relação ao delito de associação para o tráfico imputados aos réus e o delito de tráfico de drogas imputado à ré Tainá, há que se reconhecer que os elementos de convicção em relação a tais delitos não são suficientes a justificar um decreto condenatório. Passo, de início, a apresentar o teor da prova testemunhal e dos interrogatórios.

O réu, em juízo, confirmou que, além de já ter sido preso por associação para o tráfico e receptação, está preso provisoriamente também porque acusado de tentativa de latrocínio. Quanto aos fatos ora apurados, disse que, na noite anterior aos fatos, pernoitou na casa da namorada Tainá. Afirmou que os policiais chegaram em sua residência indagando-o sobre uma arma, que ele respondeu não possuir, indicando apenas onde estavam as drogas. Em seguida, questionaram-no sobre seu documento, momento em que respondeu que estava na casa da corré Tainá. Com essa informação, os policiais se deslocaram até a casa da corré e o interrogando, indicando o endereço, os acompanhou. Quando lá chegaram, os policiais, objetivando entrar no imóvel, forçaram o portão. Pelo que soube, encontraram drogas na residência da corré.

Ademais, disse que o Delegado continuou perguntando a respeito da arma de fogo, afirmando que localiza-la era o objetivo da diligência. Em relação à organização criminosa “PCC”, negou ser integrante e, em relação às drogas, confirmou que se destinavam à venda. Explicou que possuía algumas dívidas e que conhecidos forneciam as drogas para que ele guardasse e revendesse. Sobre o caderno apreendido, confirmou que as anotações nele contidas eram dele e que se referiam a venda de drogas. Em relação às munições, pontuou que estavam em sua casa fazia muito tempo. Questionado, disse ter escondido as drogas na casa da corré um dia antes da diligência policial e negou que ela soubesse da existência dos entorpecentes. Assim o fez porque, além de evitar a ciência de sua mãe, aproveitava quando saía da casa de sua namorada para fazer entregas. Consignou que a corré não sabia que ele era traficante.

A ré, em juízo, negou a prática delitiva. Afirmou que namora o corréu, trabalha como manicure e não sabia que o primeiro escondera drogas em seu quarto. Reconheceu a propriedade apenas das porções de maconha que entregou aos policiais. Não sabe o local exato em que as drogas que estavam em seu quarto foram localizadas. Em relação ao caderno, que pertencia a seu namorado, confirmou que o abriu e leu, mas achou que se tratava de um caderno escolar. Ademais, disse que o corréu pernoitava, de forma costumeira, em sua casa e que, por mais que soubesse do seu envolvimento com drogas, não sabia que, à época, ele estava traficando. Por fim, alegou ter ficado surpresa com a localização das drogas em seu quarto e que, quando os

policiais lá chegaram, diziam estar a procura de uma arma de fogo.

A investigadora de polícia Ariane dos Santos, afirmou, em juízo, que a Delegacia de Orlândia investigava um crime de latrocínio tentado e, no dia dos fatos, foi expedido um mandado de busca e apreensão. Na ocasião, juntamente com a polícia militar, auxiliou no cumprimento do mandado e, quando chegaram na casa do réu Ariel, ele estava acompanhado de dois irmãos e usava um cigarro de maconha. Após efetuarem buscas no imóvel, encontraram tijolos de maconha e porção de cocaína nos fundos, dinheiro e outra porção de cocaína na sala, munições de diferentes calibres no quarto e mais de cem porções de crack e outra porção de maconha na parte da frente do local. Questionado sobre os documentos, disse que o réu afirmou que eles e outros pertences estavam na casa da corré, afirmando que ele pernoitava, de forma costumeira, na residência da última. Em razão disso, se deslocaram até à residência da ré Tainá, oportunidade em que sua avó franqueou a entrada policial. Após recebê-los, Tainá afirmou que alguns pertences de Ariel estavam em seu quarto. Em seguida, a ré entregou para a depoente uma porção de maconha e cartelinhas de LSD. Todavia, em buscas no quarto, encontraram, em uma gaveta de roupas íntimas da ré, porções de cocaína e crack. Questionada, a ré admitiu que fazia uso de maconha e LSD, afirmando que não tinha conhecimento do restante das drogas. A depoente ressaltou, uma vez mais, que os pinos de cocaína estavam dentro de uma gaveta no guarda-roupa da ré, local em que encontraram também os escritos referidos pelo acusado. Disse que leu os escritos, afirmando que eram nomes de cidade e de pessoas, ficando claro que era utilizado para controlar a entrada de membros na organização criminosa. Em relação aos réus, negou que os conhecia e, em relação às buscas, afirmou que foram acompanhadas pela avó da acusada e por um tio. Afirmou, ainda, que Marilda, avó da ré, demonstrou bastante preocupação com a neta e ficou constrangida. Ademais, afirmou que o quarto da ré era pequeno, que havia peças de roupas masculinas, possivelmente do réu Ariel, e que parecia que estavam prestar a morar juntos, vez que o quarto abrigava inclusive uma máquina de lavar roupas. Disse que o réu confessou a traficância e, em relação à diligência, foi acompanhada pelo policial Marcelo e pelo investigador Milton. Ao cabo, disse que, por se tratar de mulher, entrou sozinha no quarto da ré e realizou as buscas no local.

O investigador de polícia Marcelo Ferreira Francisco, em juízo, disse que, no dia dos fatos, a Delegacia de Orlândia conduzia uma investigação referente a um delito de latrocínio e que auxiliou no cumprimento de mandados de busca e apreensão. Quando chegaram na casa do réu, encontraram-no fazendo uso de um cigarro de maconha. Ao realizarem as buscas, encontraram três tijolos de drogas, porções de crack, munições de arma de fogo e anotações do tráfico. Questionado, afirmou que o réu admitiu a traficância. Lembra que o objetivo da diligência era localizar a arma do crime de latrocínio e que o réu apontou que, na casa de sua namorada, havia mais entorpecentes. Por fim, disse que se deslocaram até à residência da ré, que não participou das buscas no local, vez que permaneceu vigiando o réu na viatura, e que foram localizadas outras porções de drogas. Afirmou que a equipe que realizou as buscas no imóvel teve a entrada autorizada.

O investigador de polícia Milton Antônio Bernardo, em juízo, disse que, em razão de um roubo ocorrido na cidade, foram expedidos diversos mandados de busca domiciliar. Afirmou que, ao realizarem as buscas na casa do acusado, apreenderam, no quarto dos fundos, tabletes de maconha. Explicou que o delegado Dr. Paulo chefiava a equipe e que, quando estavam na residência do réu, surgiu a informação de que a arma utilizada no crime de roubo estaria na casa da namorada do réu. Em razão disso, uma equipe se deslocou até lá. Disse que não participou das buscas realizadas naquele local e que não se recorda quem passou a informação de que a arma lá estava. No mais, confirmou que conhecia o réu de vista e que havia, no meio policial, informações sobre seu envolvimento com o tráfico. Por fim, disse que o irmão de Ariel estava com um cigarro de maconha quando da diligência policial e que foi registrado contra ele um boletim de ocorrência por porte de droga.

O policial militar Júlio César Caetano da Silva, em juízo, disse que, no dia dos fatos, auxiliou no cumprimento de mandados de busca e apreensão. Em buscas na casa do réu, encontraram, em um quarto nos fundos, três tijolos de maconha e porções a granel da mesma droga. Encontraram, também, balança de precisão em funcionamento,

dois comprimidos de ecstasy, 116 porções de crack na garagem e, na estante da casa, R\$ 266,00 em dinheiro. Disse que o réu admitiu a propriedade dos entorpecentes, das munições e do dinheiro. Por fim, afirmou que ele atestou que seu documento de identidade e mais drogas estavam na residência da namorada. No mais, negou que conhecia os acusados e disse não ter participado das buscas na casa da ré Tainá. O delegado de polícia Dr. Paulo Sérgio Francolin Júnior, arrolado pela defesa, disse, em juízo, que a diligência policial foi antecedida de uma investigação de latrocínio comandada pelo colega Dr. Clodoaldo, e que o depoente participou apenas do cumprimento dos mandados. Afirmou que, na casa do réu, apreenderam uma grande quantidade de drogas e, quando lá estavam, surgiram informações de que a arma de fogo estaria em um lavador de veículos e que os documentos pessoais do réu e mais drogas estavam na residência de sua namorada. Disse que dividiu a equipe e parte foi até à residência da Tainá e a outra ao lavador. Acompanhou a equipe que foi até o lavador e, em buscas no local, não foi localizada a arma. Posteriormente, ao ser informado do encontro de porções de droga na residência da ré, foi até o local, ocasião em que lhe exibiram os entorpecentes e o caderno apreendido. Em relação à entrada policial na residência da ré, afirmou que a avó de Tainá, quando ouvida na Delegacia, confirmou ao depoente que autorizou a entrada. Questionado, disse desconhecer se existia investigação anterior de tráfico envolvendo o réu. Por fim, atestou que orienta os policiais civis, em casos que não há mandado expedido, a obter a autorização dos moradores antes de ingressarem nos imóveis. Asseverou que o réu lhe disse que ficava mais na casa da namorada.

Anota-se que a palavra dos policiais militares e civis que participaram da ocorrência e da investigação gozam de relevante valor probante. Nesse sentido, inclusive, decide o E. TJSP:

Nesse diapasão: Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios firmes ou elementos outros de prova que lhes retirem, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção. Ao contrário do alegado pela Defesa, inexistem, de outro lado, contradições ou incoerências na prova oral acusatória. Suficiente, pois, a prova produzida para concluir-se, tal como na decisão recorrida, pela procedência da ação penal" (TJ-SP - APL: 282502120098260554 SP 0028250-21.2009.8.26.0554, Relator: Otávio de Almeida Toledo Data de Julgamento: 14/02/2012, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/02/2012.)

A testemunha Marilda Clemente Ferreira da Cruz, avó da ré, disse, em juízo, que estava em casa quando os policiais, após tocarem a campainha, levantaram o portão. Foi atendê-los e, quando lá chegou, perguntaram se a ré morava no local. Lembra que os policiais afirmaram que queriam falar com a ré e, ao virar as costas para chamá-la, eles a acompanharam. Disse que ficou sem reação e que eles não pediram autorização para ingressar no imóvel e nem mostraram ordem judicial. Ademais, afirmou que chegou a passar mal e que, quando estava na delegacia, a filha Renata a acompanhou. Questionada, disse que sequer chegou a assinar o depoimento porque se sentiu muito mal. Pontuou, ainda, que além de desconhecer a razão pela qual a neta foi presa, desconhece o que foi apreendido no quarto da última, sabendo apenas que a neta é usuária de maconha e que nunca lhe deu problema. Por fim, disse que Tainá, depois da prisão, lhe contou que não sabia sobre as drogas que estavam em seu quarto. Afirmou que a neta não contatou o réu depois que ele foi preso, que não conhecia os policiais que foram em sua casa e que quase não entrava no quarto da neta.

A testemunha Renata Clemente da Silva, tia da ré, disse, em juízo, que foi até à delegacia quando soube que a mãe lá estava. Assim que chegou, pediu para acompanhá-la no depoimento, o que foi permitido. Afirmou que, todavia, a genitora passou mal e foi preciso chamar o SAMU. Em relação à entrada dos policiais na residência, afirmou que sua mãe narrou que abriu o portão, momento em que eles perguntaram sobre Tainá. Quando foi chamá-la, eles já ingressaram no imóvel. Questionada, afirmou não se recordar do conteúdo do depoimento e que, até onde sabe, Tainá não tem envolvimento com drogas. Em relação a Ariel, confirmou que ele é namorado da

Tainá e que frequenta a casa e o quarto da última. Ao ser questionada, disse que não leu o depoimento que assinou pela mãe porque estava preocupada com sua saúde e que não sabe se o delegado tinha algum motivo para prejudicar a sobrinha. Exposto o teor da prova testemunhal e do interrogatório, passo a analisar a autoria delitiva e a efetiva configuração dos elementos típicos de cada um dos delitos imputados aos réus.

Tráfico de Drogas

Pois bem. Coligindo os depoimentos prestados e a dinâmica dos fatos, conclui-se que a maioria esmagadora da droga pertencia apenas ao acusado Ariel. Observe-se que (i) ele confirmou, em ambas fases da persecução, a propriedade das drogas, e (ii) conforme atestam os policiais que cumpriram o mandado de busca domiciliar, as drogas foram localizadas, em maior quantidade, na residência do último. Em relação à ré Tainá, note-se que sua suposta autoria funda-se no fato de que fora localizado em seu quarto (i) drogas de 4 (quatro) diferentes espécies, ainda que não em grande quantidade, e (ii) um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas. Em juízo, a ré, além de afirmar que o caderno apreendido pertencia ao corréu, declarou não saber que ele guardava drogas em sua casa. No mesmo sentido, o réu, também em juízo, confirmou a propriedade do caderno e das drogas e afirmou que, sem que a namorada soubesse, as escondeu em sua residência na noite anterior à diligência policial. Asseverou que guardou tais entorpecentes no quarto de Tainá para que pudesse vendê-los posteriormente. Nota-se que restou incontroverso, inclusive pela palavra dos investigadores, que Ariel pernoitava na casa de sua namorada de forma costumeira, o que empresta verossimilhança a tal versão. Ainda, o laudo pericial anexado às fls. 394/399 atestou que os vocábulos presentes no caderno provieram do punho do acusado. Fato é que os réus, durante toda a persecução penal, apresentaram relatos uníssonos indicando que Tainá não tinha ciência da droga que estava em sua residência. Até mesmo quando da própria diligência fora essa a versão por eles apresentada aos investigadores.

Nesse ponto, respeitada a posição do I. Promotor de Justiça, há que se concluir que a única droga efetivamente pertencente a Tainá fora aquela por ela entregue aos investigadores, logo em um primeiro momento (pequena porção de maconha e uma cartelinha de LSD), destinadas ao seu uso. O exato local em que localizadas as porções, por si só, somado a outras circunstâncias, não leva a conclusão, acima de qualquer dúvida razoável, de que Tainá tinha ciência do restante das drogas apreendidas em seu quarto e sabia que elas se destinavam ao tráfico. Por mais que a versão apresentada na exordial acusatória também seja verossímil, ou seja, mesmo que seja possível e até provável que Tainá soubesse das drogas escondidas, não há como excluir, com segurança, a versão em sentido contrário. Há que se aferir, assim, a efetiva destinação do entorpecente pertencente a Ariel.

Nessa esteira, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o intuito da traficância pode ser inferido pela quantidade, forma de acondicionamento da droga, comportamento do acusado logo antes ou no momento da apreensão, sendo desnecessário que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Nesse sentido:

A natureza altamente lesiva e a quantidade de porções da droga capturada, somadas à apreensão de apetrechos geralmente utilizados no preparo e disseminação de tóxicos, bem como de certa quantia em dinheiro, são fatores que indicam envolvimento maior com a traficância, autorizando a preventiva. (HC 323.748/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, REPDJe 05/10/2015, DJe 28/09/2015).

TRÁFICO. Conduta de manter em depósito, para fornecimento a consumo de terceiros, 141 gramas de maconha, acondicionados em 109 porções individualizadas.

Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão parcial. Alegada posse de parte da droga apreendida. Destinação para seu próprio consumo. Versão isolada. Depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Condenação mantida. Natureza, quantidade e modo de acondicionamento. Apreensão de R\$119,00 e de balança de precisão. Não comprovação de atividade lícita remunerada. Sinais indicativos do intuito mercantil. PENA. Acréscimo da pena-base por conta dos maus antecedentes. Afastamento por ostentar o réu apenas uma condenação definitiva.

Redução para o mínimo legal. Elevação de 1/6 por força da reincidência específica. Concretização em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa. Regime fechado. Recurso defensivo parcialmente provido. (TJSP, Relator(a): Otávio de Almeida Toledo; Comarca: Sorocaba; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 05/07/2016; Data de registro: 06/07/2016).

Na espécie, verifica-se que foram localizados (i) diversos tipos de entorpecentes (maconha, crack, cocaína, "LSD" e ecstasy - vide laudo de constatação anexado às fls. 43/47 e complementado pelo laudo definitivo de fls. 193/198), (ii) uma balança digital, uma faca de cozinha e duas navalhas, todos com resquícios de cocaína e (iii) uma certa quantia em dinheiro. Todos esses elementos, em conjunto, denotam que a droga se destinava a venda. Soma-se a isso o fato de que o acusado, nas duas fases da persecução, confessou integralmente a prática delitiva. Reconhece-se, portanto, que a droga apreendida efetivamente destinava-se à mercancia espúria. Ante todos esses elementos, imperioso concluir que a droga pertencente ao acusado Ariel destinava-se ao tráfico. Perfeita a adequação típica de sua conduta ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e ausentes causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade, a condenação pelo delito de tráfico de drogas se impõe.

Desclassificação e porte de drogas.

Patente a materialidade delitiva e a autoria de Tainá referente ao delito de porte de drogas para consumo pessoal. Isso porque (i) reconhece-se que com ela foi localizada pequena quantidade de drogas e (ii) inexistem outros elementos indicativos de que ela estaria traficando, conforme supramencionado. A ré, inclusive, confessou a prática deste delito.

Nessa esteira, presentes os elementos típicos veiculados no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, e ausentes causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação de Tainá por tal delito se impõe.

Associação para o tráfico.

Reconhece-se, de início, que segundo o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, "para configuração do tipo de associação para o tráfico, é necessário que haja estabilidade e permanência na associação criminosa. Dessa forma, é atípica a conduta se não houver ânimo associativo permanente (duradouro), mas apenas esporádico (eventual)." (STJ. 5ª Turma. HC 248844/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/05/2013).

No caso, considerando que não foi reconhecida a responsabilidade criminal da ré Tainá pelo delito de tráfico de drogas, não há que se falar em associação para o tráfico. Mesmo que assim não fosse, fato é que o próprio Ministério Público sustentou, em alegações finais, que não restaram provados os elementos do tipo penal, ante a ausência de ânimo associativo permanente. Em razão disso, sem maiores delongas, a absolvição dos acusados pelo delito de associação para o tráfico se impõe.

Posse irregular de munições de uso permitido.

Já em relação a posse irregular de munições de uso permitido, incontroversa a autoria de Ariel e a configuração dos elementos típicos. Observe-se que o réu confessa que as munições apreendidas em sua residência lhe pertenciam. Ademais, de acordo com o laudo anexado às fls. 182/191, as munições, nos testes realizados, se mostraram eficazes para o disparo. Vale ressaltar que o porte ou a posse da arma de fogo é fato típico, mesmo quando não gera perigo em concreto, vez que se trata de delito de perigo abstrato:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUCTA. ORDEM DENEGADA. 1. O tipo penal do art. 14, da Lei nº 10.826/03, ao prever as condutas de portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de portar ilegalmente a munição. 2. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 119154, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013,

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 10-12-2013 PUBLIC 11-12-2013) PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSE APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. TEMAS NÃO SUSCITADOS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

Por fim, não vislumbro a presença de eventual estado de necessidade, causa de exclusão da ilicitude. Ora, seria necessário, para seu reconhecimento, que o acusado comprova-se a real existência do perigo atual ou iminente, assim como sua inevitabilidade, o que não ocorreu. Nesse sentido:

Porte de arma - Autoria e materialidade comprovadas - Alegação de porte de arma por estado de necessidade - Inconsistência - Excludente que exige, para seu reconhecimento, a comprovação de perigo atual ou iminente, além de inevitável, não demonstrado no caso dos autos - Condenação mantida. 2. Porte de arma - Réu que ostenta condenação anterior por homicídio consumado e qualificado - Elementos que indicam se tratar de portador de maus antecedentes e já demonstrou ser pessoa de personalidade violenta, de forma a não fazer jus ao benefício do 'sursis' ou à simples aplicação de pena restritiva de direitos, assim como não faz jus a iniciar o desconto da pena de prisão no regime mais brando. (TJ-SP - ACR: 1134204370000000 SP, Relator: Elias Junior de Aguiar Bezerra, Data de Julgamento: 04/11/2008, 14ª Câmara de Direito Criminal C, Data de Publicação: 03/12/2008)

Nessa senda, perfeita a adequação típica ao disposto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, e inexistentes causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade, a condenação se impõe.

Por fim, considerando que o acusado Ariel se valeu de mais de uma conduta para praticar os delitos de tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido, estamos diante do concurso de crimes de natureza material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Delineadas as condutas delitivas, passo a dosar as penas.

Pena

Ariel

Tráfico de Drogas.

No tocante à primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas), verifico que inexistem elementos para exasperação em virtude de maus antecedentes, conduta social ou da personalidade da agente considerando que "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base" (Súmula 444 do STJ e STF, plenário, RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17/12/2014 - repercussão geral). No mais, a "conduta social" representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais (vide STF, 2ª Turma, HC nº 340.007/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/12/2015).

Em sentido análogo, a culpabilidade, o comportamento da vítima, os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal (vide STJ, 5ª Turma, HC nº 227.302/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 21/08/2012).

Lado outro, vislumbro que a natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas (cocaína, maconha, crack, LSD e ecstasy) demonstram a maior potencialidade lesiva e gravidade da conduta da agente. Assim, em virtude de duas circunstâncias negativas (natureza da droga e quantidade das drogas), exaspero a pena-base em 1/5 (um quinto), fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante da confissão. Presente, lado outro, a agravante referente à reincidência (condenações nos autos nº 0000364-31.2021.8.26.0404 e nº 0003969-19.2016.8.26.0404 - certidões de objeto e pé às fls. 96/97). Considerando a jurisprudência dos tribunais superiores, tratando-se de duas condenações a gerar reincidência, a denotar a presença de multirreincidência, deixo de compensar agravante e atenuante. Nessa senda, exaspero a pena intermediária em 1/6 (um sexto), fixando-a, assim, em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não se fazem presentes causas de diminuição e de

aumento da pena. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Fixo o dia-multa no mínimo legal por desconhecer a capacidade econômica do agente.

Porte de arma de fogo

No tocante à primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas), verifico que inexistem elementos para exasperação em virtude de maus antecedentes, conduta social ou da personalidade da agente considerando que “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula 444 do STJ e STF, plenário, RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17/12/2014 – repercussão geral). No mais, a “conduta social” representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais (vide STF, 2º Turma, HC nº 340.007/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/12/2015).

Em sentido análogo, a culpabilidade, o comportamento da vítima, os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal (vide STJ, 5º Turma, HC nº 227.302/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 21/08/2012).

Assim, mantenho a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante da confissão. Presente, lado outro, a agravante referente à reincidência (condenações nos autos nº 0000364-31.2021.8.26.0404 e nº 0003969-19.2016.8.26.0404 – certidões de objeto e pé às fls. 96/97). Considerando a jurisprudência dos tribunais superiores, tratando-se de duas condenações a gerar reincidência, a denotar a presença de multirreincidência, deixo de compensar agravante e atenuante. Nessa senda, exaspero a pena intermediária em 1/6 (um sexto), fixando-a, assim, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não se fazem presentes causas de diminuição e de aumento da pena. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa. Fixo o dia-multa no mínimo legal por desconhecer a capacidade econômica do agente.

Concurso de crimes.

A despeito da configuração do concurso material, inviável a aplicação do cúmulo material, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que as penas corporais de ambos os delitos são de natureza distinta.

Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência específica e a extrema gravidade em concreto da conduta, nos termos do art. 33, §2º e 3º, do CP, estabeleço como regime inicial o fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão e o semiaberto para o início do cumprimento da pena de detenção.

Considerando que se encontram preso há 6 (seis) meses e considerando a quantidade de pena aplicada, inviável a aplicação do disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Tainá.

Considerando que a ré é primária e ostenta bons antecedentes, mostra-se razoável sua condenação à pena de advertência, nos termos do art. 28, inc. I, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE o pedido formulado pelo Ministério Público na inicial acusatória, para:

(i) CONDENAR o réu ARIEL FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12, caput, da Lei nº 10.823/06, na forma do art. 69 do Código Penal, às respectivas penas de (a) 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, fixado este no mínimo legal, e (ii) 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, fixado este no mínimo legal;

(ii) ABSOLVER os réus ARIEL FERREIRA DOS SANTOS e TAINÁ CLEMENTE CAMARGO, qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº

11.343/06, o que faço com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, e;

(iii) CONDENAR a ré TAINÁ CLEMENTE CAMARGO, qualificada nos autos, como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência.

Ausentes os requisitos legais, em especial a quantidade de pena fixada e a reincidência do acusado ARIEL, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, ou a aplicação do sursis, nos termos do art. 77 do CP.

Em relação a ARIEL, patente a presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva. Isso porque sua liberdade apresenta patente risco à ordem pública, considerando a extrema gravidade em concreto de sua conduta (vide a quantidade e variedade de drogas com ele localizada). Fato é que o acusado já foi condenado por associação para o tráfico e, mesmo após o cumprimento da pena, tornou a traficar, fazendo da mercancia espúria verdadeiro meio de vida, o que denota que, se em liberdade, tornará a delinquir. Recomende-se que continue recolhido no estabelecimento prisional que já se encontra.

Com o trânsito em julgado: (1) oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para cadastro de dados criminais; (2) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para os fins do art. 15, III, da CRFB; (3) intímem-se os réus para pagamento da multa aplicada no prazo de 10 (dez) dias, e (4) expeça-se guia de execução definitiva.

Determino, ainda, o perdimento dos bens apreendidos (dinheiro e aparelhos de telefonia celular), em favor da União, nos termos do art. 91, inc. II, alíneas a e b, do Código Penal, combinado com o art. 63 da lei nº 11.343/06, vez que todos tais objetos foram apreendidos em contexto de tráfico de droga, sendo que o numerário (fls. 165) constitui produto do crime ao passo que os aparelhos de telefonia eram utilizados na prática do delito (vide laudo pericial de fls. 273/291). Lado outro, considerando que a perícia já foi realizada e por não possuir valor econômico, promova-se a destruição (i) das munições de arma de fogo apreendidas, (ii) da balança de precisão, (iii) dos cadernos e demais objetos apreendidos.

Lado outro, por não se qualificar como instrumento do crime, promova-se a devolução do telefone celular pertencente à ré Tainá (celular da marca Iphone 6 cor prata).

Custas ex lege.

Para os advogados eventualmente nomeados, arbitro os honorários no máximo da Tabela Defensoria Pública. Transitado em julgado, expeça-se a certidão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Orlandia, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA